

1500707-31.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500707-31.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500707-31.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VINICIUS ADRIANO GARCIA LOPES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

VINICIUS ADRIANO GARCIA LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e no art. 33, § 1º, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06; e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, todos combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Consta que no dia 14 de maio de 2021, por volta das 19h10min, na Avenida Marco Constantini, 2.011, nesta cidade e comarca, guardava e mantinha em depósito, o réu, para futura entrega a terceiros, doze porções de "maconha", pesando 1.406,99g; sete porções de "haxixe", pesando 27,64g; oito embalagens de "maconha líquida", pesando 113,43g; e sessenta e três comprimidos de "ecstasy", substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portar dois aparelhos celulares, três rolos de plástico filme, uma seladora a vácuo, duas balanças digitais e R\$ 24.000,00.

Teria, ainda, utilizado o réu, o imóvel, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, possuía e mantinha sob guarda, o réu, dois revólveres "Rossi" e "Taurus" calibre 38, municiados, cada um, com seis cartuchos intactos e mais oito cartuchos intactos do mesmo calibre, além de uma espingarda calibre 28, todos de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, perseguiram e abordaram Julian Roberto Peres, que tentou fugir na condução do veículo "Ford/Fiesta", placas EGE-6298, ao perceber a viatura, localizando-se, no painel central do automóvel, uma porção de "maconha" e onze comprimidos de "ecstasy". Para os agentes, Julian Roberto Peres apontou ter adquirido os entorpecentes com o réu.

Em seguida, realizaram os policiais buscas no imóvel do denunciado, onde encontraram, em diversos cômodos, por indicação deste, o restante dos tóxicos, os petrechos, os celulares, as armas, as munições e o dinheiro.

Oferecida a denúncia foi o réu notificado e apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas quatro testemunhas comuns e três apontadas pela defesa.

Após, foi interrogado o réu.

Em alegações finais, via memoriais, a representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 481/488).

A defesa pleiteia, preliminarmente, nulidade processual ao sustentar ausência de justa causa para busca pessoal, violação de domicílio, e quebra da cadeia de custódia; bem como, no mérito, a absolvição do réu arguindo, em suma, insuficiência de provas a delinear os crimes, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 442/478).

É o relatório.

DECIDO.

Em sede preliminar.

Ao contrário do alegado pela defesa, não há nulidade na abordagem policial efetivada após nervosismo apresentado por "Alexia" e "Julian".

Isso porque, é dever da polícia ostensiva, com base em protocolos pré-existentes e de rígida elaboração, fundados, inclusive, na experiência pessoal, averiguar situações de desrespeito à ordem jurídica e social.

Ademais, in casu, não se observa qualquer indicação de violação de direitos das citadas testemunhas, as quais, espontaneamente, admitiram a aquisição de entorpecentes do réu, motivando o desfecho da diligência policial.

Além disso, por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência decorreu, por primeiro, do estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes no local, e, ao depois, de autorização do réu, que, inclusive, acompanhou toda a diligência de busca no imóvel.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância do denunciado, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial.

Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei nº 11.343/06). 2. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garante ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de

entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n. 306.560/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 3. Uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade (HC n. 310.338/SP, Relator Ministro GURGEL DE FÁRIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Para rever a conclusão da instância de origem, quanto à ausência de autorização para a entrada no domicílio, seria indispensável a revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço em recurso especial, em razão da vedação da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, REsp 1.909.082-AgRg/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 02.02.2021).

Por fim, incabível a alegação de violação da cadeia de custódia, posto terem sido preservadas, a todo momento, as substâncias tóxicas. No laudo de constatação nº 156.809/2021, elaborado em 15 de maio de 2021, constou-se a numeração dos respectivos lacres dos invólucros plásticos contendo os entorpecentes. Naquela ocasião, em cada um dos itens vistoriados, a perita pontuou: "(...) uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia" (fls. 36/40).

Posteriormente, em 18 de maio de 2021, elaborou-se o laudo complementar nº 156.811/2021, com o seguinte objetivo: "através de novos ensaios experimentais, este laudo visa ratificar os resultados apresentados quando da realização do exame de constatação químico-toxicológico 156.809/2021". Para tanto, conforme indicação da perita, foram analisadas aquelas porções de 2g, de cada substância apreendida, retidas no núcleo da polícia científica: "acondicionado sob o lacre s/n, pois trata-se de material retido neste Núcleo" (fls. 212/215).

Não seria razoável, em termos de logística, o deslocamento da integralidade da quantidade das substâncias entre o departamento policial e o instituto de criminalística, motivo pelo qual, na efetivação do laudo preliminar, são mantidas, repita-se, porções menores para eventuais análises futuras.

Assim, justificada a inexistência de indicação de lacre no laudo de fls. 212/215, preservada está a cadeia de custódia.

Enfocadas as questões acima, AFASTO as teses preliminares.

Passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 30/32, que revela o encontro dos entorpecentes, dos petrechos, dos celulares, das armas, das munições e do dinheiro em tela.

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 36/41, os laudos de exame químico toxicológicos de fls. 212/215 e 222/225, concludentes no sentido de se tratarem de Tetrahydrocannabinol - THC e de Metilenedioximetanfetamina - MDMA as substâncias encontradas.

Os petrechos foram vistoriados, constatando-se resquícios de "maconha" na seladora a vácuo e nas balanças (fls. 176/180).

Em perícia os revólveres, a espingarda e as munições (fls. 216/221), indicou-se a eficácia de todos na realização de disparos.

Os aparelhos celulares foram analisados (fls. 311/315).

Na fase policial, Vinicius admitiu a prática do comércio ilícito e justificou tal conduta em dificuldade financeira. Acrescentou serem a espingarda e o revólver "Taurus" herança de família, bem como ter adquirido o revólver "Rossi" para proteção pessoal.

Em Juízo, confirmou o réu guardar o tóxico, que se destinaria ao consumo. Afirmou vender o produto algumas vezes, provendo o dinheiro guardado, deste negócio. Quanto às armas, seriam, duas, produto de herança e, a outra, de aquisição.

Alexia da Silva Santos e Julian Roberto Santos Peres, em congruência, confirmaram haver adquirido porções de drogas do réu, sendo abordados por agentes logo após a negociação.

Tais testemunhas, em Juízo, disseram ter sido coagidos a afirmar a compra de droga

no imóvel do réu, a pedido dos policiais, que não conheciam.

Inexplicável razão para agentes policiais exigirem determinado tipo de depoimento de Alexia e Julian. Ainda que assim não fosse, teriam marido e mulher procurado solucionar a questão prontamente, caso verdadeira.

Contam os policiais que, em patrulhamento, abordaram "Julian" e "Alexia", em deslocamento no especificado automóvel, no interior do qual localizaram uma porção de "maconha" e onze comprimidos de "ecstasy", adquiridos do denunciado. Continuam os agentes no sentido da realização de busca na residência do réu, que franqueou a entrada e, espontaneamente, indicou a existência das drogas, dos petrechos e dos armamentos. Detalharam sobre o encontro, na cozinha, dos celulares, dos rolos de plástico filme, da seladora e de R\$ 716,00; no forno do fogão, de dois tijolos de "maconha", de nove porções fragmentadas desta droga, de porções de "haxixe" e das balanças; no exaustor, de um tijolo de "maconha" e dos comprimidos de "ecstasy"; na geladeira, das embalagens de "maconha líquida" e o restante do dinheiro; na cômoda, dos revólveres e das munições; bem como, no guarda-roupa, da espingarda. Para tais testemunhas admitiu o réu a prática da traficância e a propriedade de todo armamento.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os agentes incriminar o réu ou forjar os crimes. Neste sentido, vale registrar a seguinte decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

As testemunhas ouvidas em nome da defesa nada acrescentaram ao deslinde da questão. Urge consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira do réu, que não comprovou relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, sendo a negociação, guarda ou transporte do produto, medida impositiva na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT"729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Ainda, eventual dificuldade financeira, apontada pelo réu, não autorizaria, de forma alguma, a prática criminosa. Até porque, se assim não fosse, desnecessária seria a existência de normas legais, reguladoras do comportamento humano.

Em relação ao crime tipificado no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06, descabida a condenação do acusado, pois certo é ter o réu guardado e mantido em depósito, na residência, o entorpecente e os petrechos destinados à traficância, subsumindo-se tais condutas ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da

especificada Lei.

As condutas atinentes aos dois tipos penais foram cometidas no mesmo contexto fático, aplicando-se, portanto, o princípio da consunção para que o agente seja punido apenas pela finalidade última, ou seja, o tráfico de drogas.

Portanto, AFASTA-SE, em razão da consunção, a acusação de utilização de imóvel, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Nesse sentido a edição 126 de "Jurisprudência em Teses", do Superior Tribunal de Justiça: "É possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e/ou no art. 34 pelo tipificado no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta".

Urge registrar, por fim, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, caber à defesa a prova da existência de registro das armas e das munições, bem como da autorização para o réu mantê-las sob guarda, o que não aconteceu, logo, outra explicação não há exceto ter o réu praticado o crime em estudo.

Apesar da tese defensiva, inviável o reconhecimento da legítima defesa por parte do réu, sob o argumento de manter porte da arma descrita para garantir a segurança pessoal, ante supostas ameaças de morte recebidas.

Não há como consentir que o réu se valha de meios ilegais, fazendo uso irrestrito de arma, como forma de garantir a própria segurança. Tinha o acusado a alternativa de agir dentro da legalidade, mediante aquisição de arma de fogo registrada, com a devida documentação e autorização.

Assim, a análise das provas aponta, com a certeza necessária, ter o réu mantido sob guarda, armas e munições, sem o devido registro e porte.

Convencida da responsabilidade penal do acusado, passo a individualizar as penas.

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em razão da elevada quantidade e da variedade de substâncias entorpecentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

- art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03: Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão da elevada quantidade de armas e munições.

Verificada a confissão da autoria, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, reduzo a pena para 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com base no caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão; 1 (um) ano de detenção e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07) e o regime inicial da pena de detenção é o semiaberto, em razão da conduta antissocial do réu (art. 33, §3º, do Cód. Penal).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se considerou o período de prisão provisória do réu, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. Proc. Penal.

O fato de ter respondido encarcerado o réu à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na imposição de regime menos gravoso. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INEXISTENTE - PLEITO DE DETRAÇÃO - REGIME INICIAL FIXADO ADEQUADAMENTE DE ACORDO COM O ARTIGO 59 DO CP C/C ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - RECURSO DESPROVIDO. 1 -

Caracteriza-se a omissão quando a Decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. 2 - Não há omissão a ser sanada, na medida em que esta Colenda Câmara enfrentou detidamente todas as questões levantadas no apelo interposto, tendo apreciado de forma suficiente a pretensão deduzida, embasando seu entendimento na jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3 - O regime inicial de cumprimento da pena não levou em consideração o critério objetivo da pena, mas sim

o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas. 4 - O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentam a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5 - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00030386020128080047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 01/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2014).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ante a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que aponta maior periculosidade do agente, indicando dedicar-se à atividades criminosas, mesmo porque, não existe comprovação de atividade laborativa.

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno VINICIUS ADRIANO GARCIA LOPES, R.G. n.º 43.744.324, a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado; a 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e o art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "a" e "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO dos petrechos apreendidos (fls. 30/32), porque utilizados como instrumentos do crime, bem como do dinheiro e dos celulares, pois obtidos em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se promova a destruição das amostras de entorpecente, guardadas para contraprova. Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA